

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1966/2534

นาย ยุ ทศพร กฤตยาเกียร ณ
อธิบดี กรมทะเบียนการค้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 19 เบญจ วรรคท้าย,
มาตรา 38

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนฯ ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้เพราะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี ลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการฯ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนฯ โจทก์เห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการฯ ไม่ตรงด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าพิพาทได้ถูกนายทะเบียนฯ เพิกถอนแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทได้ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่า การเพิกถอนเครื่องหมายการค้ายังไม่ครบ 12 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนฯ สั่งเพิกถอน จึงต้องถือว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วยังอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าของจะใช้สิทธิยื่นขอจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 38 ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้ถูกเพิกถอนแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ และคำฟ้องของโจทก์เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นในเนื้อหาแห่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ว่าไม่ถูกต้อง

โจทก์มิได้กล่าวอ้างความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของคำวินิจฉัยดังกล่าว อาทิความบกพร่องของการเป็นกรรมการ ความไม่ชอบของการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ย่อมเป็นที่สุดตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า มาตรา 19 เบญจ วรรคท้ายโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกเป็นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อันมีใบสลากประกอบด้วยรูปนกเพนกวินเป็นสาระสำคัญ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยทั้งหกในฐานะคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งยื่นตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งนี้ไม่ตรงด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กล่าวคือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นไม่ได้ต่ออายุการใช้แล้ว และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ได้เพิกถอนออกจากทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 37 และต่อมาเจ้าของเดิมก็ได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้แล้วเครื่องหมายการค้านี้จึงไม่อยู่ในทะเบียนอย่างสิ้นเชิง โจทก์ได้รับสิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันได้ คำสั่งของจำเลยทั้งหกไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 393/2529 และสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 156686

จำเลยทั้งหกให้การว่า คำสั่งของจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนื่องจาก
เครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอน
เครื่องหมายการค้านี้ออกจากทะเบียนเพราะเจ้าของเดิมไม่ต่ออายุการใช้ แต่ตามพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 38 ก็บัญญัติว่าถ้ามีการขอจดทะเบียนขึ้นมา
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันเพิกถอนก็ให้ถือว่าเครื่องหมายนั้นยังอยู่ในทะเบียน เมื่อ
โจทก์มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ภายใน 12 เดือน โดยที่โจทก์ไม่ใช่ผู้มี
สิทธิขอจดได้ตามมาตรา 38 ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ได้ปฏิเสธคำขอของ
เจ้าของเดิมที่ขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้านี้ออกจากทะเบียนเพราะนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนไปก่อนแล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
มาตรา 37 เจ้าของเดิมไม่มีสิทธิมาขอถอนอีกได้การแสดงเจตนาของเจ้าของเดิมไม่มี
ผลเปลี่ยนแปลงของกฎหมายดังกล่าวโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอจดได้ คำสั่งของนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ทั้งคำสั่งของจำเลยทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็เป็นที่สุด
แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 19 เบญจ วรรคสามโจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะโจทก์อ้างว่า
จำเลยทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยหรือสั่งไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่ใช่เพียงแต่โต้แย้งความเห็นและข้อเท็จจริงอันจะต้องห้ามตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 19 เบญจ วรรคสาม และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งหกที่ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คำวินิจฉัยของจำเลยทั้งหกใน
ฐานะคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบแล้ว และเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 19 เบญจวรรคท้าย พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายชอร์ ยิงเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าพิพาท แต่นายชอร์ ยิงไม่ขอต่ออายุการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาท นายทะเบียนจึงสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าพิพาทออก
จากทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 วันที่ 30 มิถุนายน 2529 โจทก์ยื่นคำร้องขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาท วันที่ 21 กรกฎาคม 2529 นายชอร์ ยิง ได้โอน
เครื่องหมายการค้าพิพาทให้บุคคลอื่น และผู้รับโอนได้ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทแต่นายทะเบียนปฏิเสธไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
พิพาทให้ผู้รับโอน ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้โจทก์วันที่ 11 กันยายน 2529 นายชอร์ ยิง ได้
ขอถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาท แต่นายทะเบียนได้แจ้งว่า
เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
มาตรา 37 แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิตามมาตรา 38 ก็ให้ทำหนังสือแจ้งมาใหม่
แต่ไม่มีหนังสือของนายชอร์ ยิง แจ้งสละสิทธิดังกล่าว วันที่ 18 ธันวาคม 2529 คณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า วันที่ 3 ตุลาคม 2529 นายชอร์ ยิง ได้ขอถอนหนังสือที่ขอถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทและกลับขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
พิพาทใหม่เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2530 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนาย
ทะเบียน

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และคำวินิจฉัยของจำเลย ทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถูกต้องหรือไม่ ในปัญหาข้อแรก โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทต่อ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งได้แก่จำเลยทั้งหกนี้ จำเลยทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ฟ้องโดยอ้างในคำฟ้องว่าคำสั่งดังกล่าวของจำเลยทั้งหกไม่ตรงด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้นได้ถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ซึ่งตามคำสั่งของจำเลยทั้งหกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ปรากฏว่าจำเลยทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่า การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 92971 ยังไม่ครบ 12 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งเพิกถอน จึงต้องถือว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วยังอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าของจะใช้สิทธิยื่นขอจดทะเบียนได้ตามมาตรา 38 ฉะนั้นข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้ถูกเพิกถอนแล้วจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เช่นนี้จะเห็นได้ว่า คำฟ้องของโจทก์เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเห็นในเนื้อหาแห่งคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้นเองว่าไม่ถูกต้องชอบธรรม โจทก์มิได้กล่าวอ้างความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของคำวินิจฉัยดังกล่าว อาทิความบกพร่องของการเป็นกรรมการ ความไม่ชอบของการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น เมื่อคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งหกเป็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงย่อมถึงที่สุด

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 19 เบญจ วรรคท้าย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นต่อไป"

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ชุม สุกแสงเปล่ง-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ที่ศาลฎีกาพิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ในคดีนี้ ผู้บันทึกเห็นด้วยในผลสุดท้ายที่มีผลเท่ากับยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้สั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งน่าจะถูกต้องกับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว แต่ผู้บันทึกมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังนี้ ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเครื่องหมายการค้ารูปนกเพนกวินที่นายชอร์ ยิง จดทะเบียนไว้ในจำพวก 42 สำหรับสินค้าชอสหอยนางรมเป็นเครื่องหมายการค้าที่หมดอายุการจดทะเบียนแล้ว และนายชอร์ ยิง ไม่ขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนจึงสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง เสียจากทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 37 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2529 โจทก์ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปนกเพนกวินซึ่งเหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้า

ของนายชอร์ ยิง ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือในจำพวก 42 สำหรับสินค้าน้ำมัน
หอย จากนั้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2529 นายทะเบียนมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้โจทก์โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง ต้องห้ามตามมาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยทั้งหก จำเลยทั้งหกมีคำสั่งยื่นตามคำสั่งของนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2529 โดยมีความเห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง ที่จด
ทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน จึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจด
ทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ และเมื่อการเพิก
ถอนเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง ยังไม่ครบ 12 เดือน นับแต่วันที่นาย
ทะเบียนสั่งเพิกถอน จึงต้องถือว่าเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วยังอยู่ในระยะเวลาที่
เจ้าของจะใช้สิทธิยื่นขอจดทะเบียนได้ตามมาตรา 38 ผู้บันทึกมีความเห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้เพิกถอนจากทะเบียน
เพราะหมดอายุการจดทะเบียนแล้วตามมาตรา 37 เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงเป็น
เครื่องหมายการค้าที่มีได้มีอยู่ในทะเบียนและไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายตก
เป็นงานสาธารณะ (work in public domain) ซึ่งผู้อื่นย่อมมีความชอบธรรมที่จะใช้
เครื่องหมายการค้านั้นได้โดยไม่เป็นละเมิดต่อไป ข้อยกเว้นที่จะให้คงถือว่า
เครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนแล้วดังกล่าวยังอยู่ในทะเบียนมีเพียงประการเดียว
ตามมาตรา 38 คือ ต้องมีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ภายใน 12
เดือนนับแต่วันเพิกถอน เพราะตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้าฯ บัญญัติไว้ชัดเจนว่า "เมื่อนายทะเบียนได้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามความ
ในมาตรา 37 แล้ว ถ้ามีการขอจดทะเบียนขึ้นใหม่ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเพิก
ถอน ท่านให้ถือว่าเครื่องหมายนั้นยังอยู่ในทะเบียนวันแต่จะมีผู้มาแสดงให้เป็นที่

พอใจนายทะเบียนได้ว่า เครื่องหมายนั้นมิได้มีการใช้โดยสุจริตในระหว่างสองปีก่อนวันที่เพิกถอนนั้น"จะนั้นกฎหมายจะให้ถือว่าเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง ยังอยู่ในทะเบียนต่อเมื่อนายชอร์ ยิง มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมาภายใน 12 เดือนนับแต่วันเพิกถอน แต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏว่าก่อนที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายชอร์ ยิง ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้จึงถือไม่ได้ว่ายังคงมีเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง อยู่ในทะเบียนเมื่อไม่มีเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ในทะเบียน จึงไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อวินิจฉัยว่าเหมือนหรือคล้ายกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้ คำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 16 ดังกล่าว จึงไม่ชอบและไม่ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 ซึ่งย่อมส่งผลให้คำสั่งของจำเลยทั้งหกในฐานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยื่นตามคำสั่งของนายทะเบียนไม่ชอบไปด้วย เพราะนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วอำนาจของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็มีอยู่เฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ตรี เท่านั้น กล่าวคือ มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 และ มาตรา 22 ที่ได้ยื่นทางนายทะเบียนและสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เห็นว่าขัดต่อนโยบายแห่งรัฐเท่านั้น เมื่อเรื่องนี้นายทะเบียนไม่มีอำนาจวินิจฉัยตามมาตรา 16 คำสั่งของนายทะเบียนจึงมิใช่คำสั่งตามมาตรา 16 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในเรื่องนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถึงที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 เบญจ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้และศาลน่าจะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 393/2529 ได้ ส่วนคำขอของโจทก์ที่ขอให้สั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 156686 นั้น ผู้บันทึกเห็นว่า การรับจด

ทะเบียนหรือไม่เป็นอำนาจและดุลพินิจของนายทะเบียนโดยเฉพาะคำสั่งของนายทะเบียนที่สั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็เป็นเพียงคำสั่งที่ไม่ชอบเฉพาะประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิงเท่านั้น เพราะไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง อยู่ในทะเบียนดังได้กล่าวแล้ว มิได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนจะชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในข้ออื่นด้วยทั้งเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าในที่สุดนายชอร์ ยิง ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนอีกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2530 ซึ่งเป็นการยื่นคำขอภายใน 12 เดือน นับแต่วันเพิกถอน(3 มิถุนายน 2529) ย่อมมีผลทำให้เครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิงที่ถูกเพิกถอนไปแล้ว กลับยังอยู่ในทะเบียนต่อไปอีกด้วยผลของมาตรา 38 ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้เห็นได้ชัดว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง โดยแตกต่างกันเพียงตัวอักษรภาษาจีนในกรอบโค้งด้านบนของนายชอร์ ยิง โจทก์มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่า "น้ำมันหอยตราเพนกวิ้น" และในวงกลม 2 วงและมุมเหลี่ยมด้านล่างทั้งสองข้างในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีภาษาจีน กับภาษาจีนที่กรอบโค้งด้านล่างของโจทก์กับนายชอร์ ยิงแตกต่างกัน นอกนั้นในสาระสำคัญเหมือนกันทุกประการ เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์แสดงให้เห็นที่พอใจนายทะเบียนได้ว่า เครื่องหมายการค้าของนายชอร์ ยิง มิได้มีการใช้โดยสุจริตในระหว่าง 2 ปีก่อนวันที่เพิกถอนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงต้องห้ามตามมาตรา 16 นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์ได้ ศาลย่อมพิพากษาให้ยกคำขอในส่วนนี้ของโจทก์ได้ อนึ่ง หากพิจารณาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับในขณะนี้หากแต่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีนี้น่าจะหมดไป เพราะบทบัญญัติทำนองเดียวกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 ไม่มีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 คงมีบทบัญญัติทำนองเดียวกับมาตรา 37 เดิมโดยนำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 56 เท่านั้น. ประณัติผดุง.